

ملتقى التحكيم في العالم الاسلامي

بكلية الدراسات القضائية و الانظمة

في جامعة ام القرى

من ٨-٩/٥/١٤٣٥ هـ

ورقة عمل حول

"التحكيم في سوق الاوراق المالية"

اعداد

الدكتور/ يوسف بن مبرك الصليبي العنزي

مدير الادارة القانونية – الادارة العليا

الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة

الكويت

٢٠١٤

المبحث الاول: ماهية التحكيم و تعريفه.

أولاً: ماهية التحكيم:-

من المسلم به أن القضاء لا يمارس إلا بواسطة السلطة القضائية في الدولة باعتباره مظهر من مظاهر السيادة فالقضاء (Litigation) هو الطريق العام والأصلي في النزاعات لما تتمتع هذه السلطة به من ولاية عامة . فالدول المعاصرة تتولى ليس فقط مهمة سن التشريعات القانونية لتنظيم العلاقات بين أفراد المجتمع وتبيان حقوقهم والتزاماتهم ، بل وكذلك تعمل على وضع هذه القواعد موضوع التنفيذ وحماية هذه الحقوق وصونها من أي اعتداء ، وهي تعمل كذلك على منع الاقتضاء الذاتي لذلك فهي تعمل على إنشاء مرفق عام يتولى مهمة تطبيق القانون وتحقيق العدالة . ومع ذلك فإن التحكيم (Arbitration) هو طريق آخر للفصل في النزاعات ، حيث اعترفت الدول ببعض الأفراد بسلطة الفصل في المنازعات التي تدخل أصلاً في الولاية القضائية المقررة لجهاز القضاء . و ذلك إدراكاً منها على أهمية التحكيم ودوره الحيوي وكذلك احتراماً للإرادة أطراف (Principle Of Party Autonomy) النزاع إذا ما اتجهت إرادتهم إلى تسوية النزاع عن طريق التحكيم وليس عن طريق القضاء .

ومن ذلك يتضح أن الدول الحديثة لا تستأثر الوظيفة القضائية فقط على جهازها القضائي ، بل و تقرر إمكانية مباشرة العمل القضائي بواسطة أفراد عاديين ، لا يعدون أعضاء في الجهاز القضائي لدولة وإن كانوا يمارسون ويبشرون ذات الوظيفة . فالتحكيم هو نوع من العدالة الخاصة (Private Justice) ينظمه القانون ويسمح بمقتضاه إخراج بعض المنازعات عن ولاية القضاء العام في نطاق معينة ومتي توفرت شروط معينة ليتولى أفراد عاديين مهمة القضاء بهذه النزاعات . فالتحكيم إذن هو أسلوب أو وسيلة للفصل في المنازعات يعمل إلى جانب قضاء الدولة وتحت إشرافها ورقابتها - لتحقيق العدالة ، وأساس هذا النظام الخاص للتقاضي هو اتفاق التحكيم . حيث أن الأخير يعد هو مصدر التحكيم ، فيموجبه يتفق أطراف العقد على إحالة جميع بعض نزاعاتهم التي نشأت أو قد تنشأ بينهما بشأن علاقة قانونية محددة سواء كانت عقدية أو غير عقدية إلى التحكيم ، يتولى أفراد عاديين يختارهم الخصوم للفصل (فيما يثور بينهم أو يتحمل أن يثور من نزاع) في تلك النزاعات بحكم ملزم للأفراد . فهو إذن عقد يتفق الأطراف بمقتضاه على طرح النزاع على محكم شخص أو أشخاص يختارونهم للفصل في النزاع دون المحكمة المختصة ، وهو في ذات الوقت طريق استثنائي لفصل المنازعات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية ، حيث أجاز القانون للأفراد حق اللجوء إلى التحكيم للفصل في منازعات كانت تختص بها المحاكم أصلاً ، واختصاص هيئة التحكيم يرتكن أساساً إلى حكم القانون الذي أجاز استثناء سلب اختصاص جهات القضاء ، إلا أنه ينبغي مباشرة على اتفاق التحكيم .

ويمكن القول بناء على ذلك أن التحكيم هو نظام تعاقدي المنشأ قضائي الوظيفة . فالتحكيم ليس ذو طبيعة تعاقديه فقط بل وكذلك ذو طبيعة قضائية . وهذا ما قرره محكمة التميز أن التحكيم هو : عقد يتفق طرفان بمقتضاه على عرض المنازعات التي نشأت أو تنشأ بينهما على فرد أو أفراد متعددين ليفصلوا فيه بدلاً من المحكمة المختصة .

وتبين هذه القاعدة الطبيعية القانونية لنظام التحكيم ، فهو ليس ذو طابع تعاقدي بحث وليس في نفس الوقت قضاء عام ، و إنما هو نوع من أنواع القضاء إلى جانب قضاء الدولة ولكنه قضاء من نوع خاص حيث يجد أساسه ومصدره في اتفاق التحكيم ، حيث يلتزم أطراف اتفاق التحكيم بعرض نزاعهم على هيئة التحكيم دون القضاء للفصل فيها . وهذا يؤكد أن أساس نظام التحكيم هو إرادة الأطراف ، وأنه ذو طبيعة اتفاقية . وقد أكدت محكمة التميز الكويتية هذا المعنى، حيث قررت نظراً للطبيعة الاتفاقية التي يتسم بها التحكيم وتتخذ قواماً لوجوده ومن هنا يترتب على هذا الدفع (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لوجود اتفاق التحكيم) كافة آثار الدفع بعدم الاختصاص غير المتعلقة بالنظام العام.

وتتجلى مظاهر مبدأ سلطان الإرادة في كثير من المسائل مثل حرية الأفراد التنازل عن اللجوء إلى قضاء الدولة وإحالة نزاعهم إلى هيئة التحكيم ، اختيار أعضاء هيئة التحكيم وعددهم وسلطاتهم ، مكان التحكيم ولغته، القانون الواجب التطبيق على الموضوع وإجراءات التحكيم . ولكن لا يعني ذلك أن يطغى الطابع العقدي على الطابع القضائي الذي تقوم به هيئة التحكيم ، حيث أنها تتولى مسؤولية النظر في النزاع ودراسة الموضوع والفصل فيه بحكم ملزم للأطراف التحكيم، وهذا الحكم يتمتع

بحجية الأمر المقضي به، فالغاية المنشودة من نظام التحكيم هو الفصل والقضاء بين أطراف اتفاق التحكيم في المنازعات المعروضة علي هيئة التحكيم بحكم تحكيم حاسم وملزم . فالمهمة الفعلية لهيئة التحكيم هي مهمة قضائية ، فالتحكيم وعلي ما قررته محكمة التميز بأنه طريق استثنائي لفض الخصومات ، فالمحكم متى قبل مهمة التحكيم بعد تعيينه من أطراف التحكيم فإنه يصبح قاضياً ويمارس وظيفة قضائية ويصدر قراراً يعد حكماً حاسماً للنزاع . بل أن من أوجه الشبه بين التحكيم والقضاء هي الوظيفة التي أنيطت بكل منهم وهي الفصل في المنازعات بأحكام لها قوة التنفيذ . و يعتبر هذا الحكم عمل قضائي، ولكن نظراً لأن المحكم يستمد ولايته وسلطانه من اتفاق التحكيم وليس من القانون كما هو الحال بالنسبة لقضاة المحاكم، فإن هذا الحكم يعتبر عمل قضائي ولكن ذو طبيعة خاصة .

لذلك يتجلى لنا و بوضوح أن التحكيم في مصدره عقد يخول بموجبه أطراف العقد هيئة التحكيم لتتولى مهمة القضاء في نزاعهم المعروض عليها بحكم ملزم. وهذه الفلسفة تؤكد أن التحكيم هو قضاء إلي جانب قضاء الدولة ، ولكنه يتمتع بطبيعة خاصة هي مصدر نجاحه وازدهاره وتطوره ، وهي أن مصدره هو إرادة الأفراد، لذلك فإن التحكيم ذو أصل اتفاقي ذو مهمة قضائية .

ثانياً: تعريف مفهوم التحكيم:-

من الظاهر أن عملية إيجاد تعريف شامل جامع وعالمي لمفهوم " التحكيم " عملية صعبة جداً، صحيح أن هذا المصطلح شائع الاستعمال في معظم الأنظمة القانونية سواء في تشريعاتها الوطنية أو في اتفاقياتها الدولية، إلا أنه لم يوجد تعريف شامل لهذا المفهوم . و النظام في الكويت – مثل الكثير من الأنظمة- لم يقدم تعريف شامل لمسألة "ما المقصود بالتحكيم ؟ " ولعل أكبر مثال على ذلك ، عندما ناقشت لجنة اليونسترال مسألة فيما إذا يجب أن يتضمن القانون النموذجي تعريف التحكيم ، إلا أنه بعد الدراسة والمناقشة كان القرار أنه من غير الضروري إيجاد تعريف لمفهوم التحكيم في صلب القانون النموذجي وعند تحليل هذا القرار نجد أن هناك الملاحظة التالية:

أولاً أن ما قامت به لجنة اليونسترال – رغم إمكانياتها – مؤشر علي محاولة لم يكتب لها النجاح في إيجاد تعريف شامل وموحد لمفهوم التحكيم مقبول علي مستوي عالمي . ويمكن إرجاع ذلك إلي سببين رئيسيين ، الأول ، أن هذه المحاولة كانت هي المحاولة الأولى ، حيث أنه لم يسبق أن تكون هناك جهود جماعية دولية تحاول أن توجد تعريف موحد لمفهوم التحكيم رغم كثرة وشيوع استعماله على مستوى وطني وعالمي والسبب الثاني قد يرجع إلي صعوبة التميز بين التحكيم والأنظمة المشابه له ، مثل نظام " arbitrat irrital " في إيطاليا أو نظام " bindend advies " في هولندا أو نظام " schiedsgutachten " "في ألمانيا ، وهي أنظمة تعمل- في الحقيقة- على أساس الفصل في المسائل الواقع وليس القانون ، والتزام بالقرار الصادر عبر هذه الوسائل ملزم على أساس عقدي وليس قانوني مثل التحكيم .

وقد فضل واضعي القانون النموذجي لتحكيم احترام هذه الأنظمة و هذه المفاهيم الوطنية وعدم محاولة وضع تعريف لمفهوم التحكيم من شأنه أن يخرج مثل هذه الأنظمة من دائرة التحكيم الذي قد يكون سبباً لعدم قبول هذا النموذج كقانون لتحكيم، لذلك ترك موضوع "ما هو المقصود بالتحكيم" إلي الدول لتتناوله بطريقتها الخاصة ، واكتفى بتحديد أنواع التحكيم الحر و المؤسسي، حيث جاء في نص المادة (٢) "التحكيم يعني أي تحكيم سواء تولته مؤسسة دائمة أم لا". و كذلك فعل المشرع المصري في المادة (٤) و التي بينت أنه:

" ينصرف لفظ التحكيم في حكم هذا القانون إلى التحكيم الذي يتفق عليه طرفا النزاع بإرادتهما الحرة سواء كانت الجهة التي تتولى إجراءات بمقتضى اتفاق الطرفين منظمة أو مركز دائم أو لم يكن كذلك ."

ثانياً ويبدو أن رغم أهمية تحديد المفهوم المقصود من " التحكيم " لا سيما لتحديد مجال تطبيق قانون التحكيم ، ولعل عجز أو صعوبة إيجاد تعريف تشريعي لهذا المفهوم قد يشكل ميزة عملية . حيث أنه يمنح دوراً مهماً ومحورياً للمحكمة الوطنية أن تسد هذا الثغر والفراغ التشريعي عن طريق تحديد فيما إذا كان هناك تحكيم أم لا ؟ وذلك بالنظر إلي الاتفاق وطبيعة الإجراءات

المتبعة ، ودور الهيئة التي تتولى الإجراءات ، وطبيعة القرارات التي تنتهي إليها . بمعنى آخر ، يكون للقضاء الكلمة في تحديد مفهوم التحكيم ، وهي تبني قرارها على أساس هل هناك اتفاق تحكيم ، إجراءات تحكيم ، هيئة تحكيم وحكم تحكيم . و لعل قضاء الدولة قادراً على أن يلعب هذا الدور مترجماً فهمه و معرفته لنظام التحكيم وأساسه وطبيعته وفلسفته و مكانته كوسيلة لتسوية المنازعات. وهذه المحكمة الدستورية العليا في مصر تقدم تعريفها لمفهوم التحكيم فتقول:

"(هو) عرض نزاع معين بين طرفين على محكم من الأغيار يُعين باختيارهم أو بتفويض منهما أو على ضوء شروط يحددها، ليفصل هذا المحكم في ذلك النزاع بقرار نائياً من شبهة الممالة، مجرداً من التحامل و قاطعاً لدابر الخصومة في جوانبها التي أحالها الطرفان إليه، بعد أن يدلي كل منهما بوجهة نظره تفصيلاً من خلال ضمانات التقاضي الرئيسي ."

كما وقد قدم الفقهاء -على مر الزمن - تعاريف محاولين تحديد إطار مفهوم التحكيم ، وكلها جاءت متشابهة ومتطابقة ، إلا أنها قد وردت في مفردات مترادفة لغوياً تعطي ذات المعنى وتحقق ذات المغزى ، ومن ذلك على سبيل المثال :

"قيل بأنه التحكيم هو نظام خاص للتقاضي ينظمه القانون ويسمح بمقتضاه للخصوم في منازعات معينة بأن يتفقوا على إخراج منازعه قائمة أو مستقبلية عن ولاية القضاء العام في الدولة ، وذلك لكي تحل هذه المنازعات بواسطة شخص أو أشخاص عاديين يختارهم الخصوم ويسندون إليهم الفصل في النزاع. "

وكذلك قيل بأنه اتفاق على طرح النزاع على شخص معين أو أشخاص معينين ليفصلوا فيه دون المحكمة المختصة .

وفي تعريف آخر " التحكيم هو اتفاق بين طرفين أو أكثر على تفويض هيئة تحكيم مكونة من شخص أو أكثر للفصل في نزاع بينهم بحكم ملزم. و عليه فإن التحكيم يعد في مرحلته الأولى اتفاق، وفي المرحلة الثانية إجراء وفي مرحلته الثالثة قضاء ملزم "

و نختتم بتعريف آخر، " التحكيم هو أسلوب لفص المنازعات ملزم لأطرافها، مبني على اختيار الخصوم أفراد عاديين للفصل فيما يثور بينهم أو يحتمل أن يثور بينهم من نزاع. " .

و من ذلك نستطيع أن نلخص أهم سمات نظام التحكيم حتى يسهل التعرف عليه وهي على النحو التالي:

أولاً: أن مصدر التحكيم هو إرادة الخصوم والمتمثل في اتفاق التحكيم سواء كان قد اتخذ صورة شرط التحكيم أو مشارطة التحكيم.

ثانياً: أن الغاية منه هو الفصل في النزاع، وهو ما يقصد منه الوظيفة القضائية ، حيث تتولى هيئة التحكيم مهمة الفصل في النزاع.

ثالثاً : أن ثمرة التحكيم هو إصدار حكم التحكيم ، حيث تتولى هيئة التحكيم بعد نظر النزاع أن تصدر حكمها الملزم . وقد قررت محكمة التمييز أن حكم التحكيم هو عمل قضائي ذو طبيعة خاصة ، وجاء في حكمها:

"من المقرر وفقاً لنص المادة ١٧٣ من قانون المرافعات المدنية والتجارية وما بعدها أن حكم المحكمين وإن كان قضاءً يفصل في خصومة وله حجته المانعة من إعادة طرح النزاع الذي حسمه علي جهة القضاء عن أخرى ، إلا أنه عمل قضائي ذو طبيعة خاصة أساسها أن المحكم لا يستمد ولايته من القانون كما هو الحال بالنسبة لقضاء المحاكم وإنما يستمدّها من اتفاق الخصوم على تحكيمه ذلك الاتفاق الذي أجاز له المشرع ليغني الخصوم بالتحكيم عن الالتجاء إلي القضاء وما يقتضيه ذلك من وقت وجهد ونفقات . "

و نخلص من ذلك أن التحكيم هو نوع من العدالة الخاصة ينظمه القانون ويجيز بمقتضاه إخراج بعض المنازعات عن ولاية القضاء العام في حالات معينة ليتولى أشخاص عاديين مهمة الفصل في هذه المنازعات بحكم ملزم.

المبحث الثاني: سمات نظام التحكيم في سوق الأوراق المالية

أولاً: تقنين مبادئ التحكيم المستقر عليها و الحديثة:

١. احترام مبدأ سلطان الإرادة:

إن من أبرز سمات ومميزات التحكيم هو مبدأ سلطان الإرادة. وتنشئ فلسفة هذا المبدأ من حقيقة أن التحكيم وسيلة اتفاقية لتسوية المنازعات، وتعكس إرادة ورغبة أطراف النزاع على اختيارهم لهذه الطريقة في تسوية منازعاتهم. أضف إلى ذلك أن هذا المبدأ محور أساسي في التمييز بين التحكيم والتقاضي. ولعل تقنين هذا المبدأ يظهر مدى احترام ذلك النظام القانوني لإرادة المتحايكين وخاصة التحكيم، كما أنه يمنحهم رضى نفسي وأمان تجاه احترام هذا النظام لمعظم ما اتفق عليه المتحايكين .

من ناحية أخرى، يجعل تقنين هذا المبدأ التزام على المحكمة لاحترام حرية الأفراد وعدم مخالفة ذلك. وبالاطلاع على القوانين الحديثة نجد أنها عامرة بعبارات " للأفراد الاتفاق على " أو " ما لم يتفق على خلاف ذلك "... بل إن القانون الانجليزي يقنن هذا المبدأ بطريقة فريدة حيث جعل في أول مبدأ من المبادئ التي أسس عليها قانون ١٩٩٦ هو هذا المبدأ حيث قررت المادة (١) فقرة (ب) على أن للأفراد الحرية في الاتفاق على كيفية حل منازعاتهم بشرط فقط أن يحترم الضمانات الأساسية في النظام العام .

ونعتقد من ذلك ، مثل هذا التقنين يؤكد من ناحية على الاعتراف ودعم مبدأ سلطان الإرادة في مجال التحكيم، ويقيد ذلك باحترام تلك الإرادة إلى النظام العام، مما يجعل توازنا معقولا ومقبولا بين تلك المبادئ .

من ذلك نوصي بترك مجال أكبر لإرادة الأطراف أن تلعب دوراً في تشكيل الهيئة وإجراءات التحكيم. ويجب التأكيد على أن النهج الحديث لدعم مبدأ استقلال وسيادة الإرادة لا يقف عند هذا الحد، بل يذهب إلى أكثر من ذلك، حيث تذهب تلك المعالجات إلى سد الثغرات في اتفاق التحكيم. حيث تأتي التشريعات لأحكام تؤكد في مستهلها على حرية الاتفاق في المسألة، ثم تلحقها بفقرة ثانية تتناول فيها حالة عدم الاتفاق وتقرر فيها الحل. ونعتقد أن التشريعات الحديثة قد تنبأت إلى احتمال وجود فراغ في اتفاق التحكيم أو أنه قد يتعذر حصول اتفاق على مسألة مثل تشكيل هيئة التحكيم أو غيرها. لذلك فهي تبادر لوضع اقتراحات للتغلب على هذه المشكلة حتى لا تعيق التحكيم ونجاحه. لذا فهي تقدم لطرفي التحكيم عند عدم اتفاقهم مثلاً على عدد وكيفية اختيار المحكمين مجموعة من الحلول. ومثال على ذلك ما قدمه القانون النموذجي وكذلك الحال في القانون الانجليزي لسنة ١٩٩٦ والقانون المصري للتحكيم. وتمثل هذه النصوص مرجعاً ليس فقط لأطراف التحكيم تمكنهم من اللجوء إليها والاسترشاد بها عند الاتفاق عن مسائل تشكيل هيئة التحكيم ، بل كذلك تعتبر معيناً للمحكمة في حالة تدخلها في تشكيل هيئة التحكيم.

و هذا كان مسلك نظام التحكيم الخاص بهيئة أسواق المال حيث :

- قرر في المادة (٣) من النظام علي صحة اتفاق التحكيم كقاعدة. حيث نص على " يقع اتفاق التحكيم صحيحاً ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك".
- كما قرر حق الاطراف علي الاتفاق علي مدة التحكيم. حيث نص في المادة (٥) " ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، يصدر حكم هيئة التحكيم خلال ستة أشهر من تاريخ أول جلسة صحيحة يعلن بها طرفي التحكيم، ويجوز لهيئة التحكيم مد الميعاد إلى شهرين، ولا يجوز إضافة مدة جديدة إلا بقرار من الهيئة بناءً على طلب مسبب من الهيئة وبعد أقصى لا يتجاوز شهر بعد مشاوره الأطراف".
- كما تناول حق الاطراف بالمساهمة بتشكيل هيئة التحكيم. حيث نص في المادة (٧) "يحق لكل طرف من طرفي النزاع – وإن تعددوا – اختيار محكم عنه من بين جداول المحكمين المودعة لدى الهيئة – أو من غيرهم – خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره – من قبل الهيئة – بذلك، وفي حالة عدم قيام أي منهم بذلك تعين الهيئة المحكم صاحب الدور من بين الجداول المودعة لدى الهيئة حسب طبيعة النزاع وتقدير أتعابه – وفق الجدول المودع – ويعرض الأمر على الطرف الآخر – في حال رغبته الاستمرار في إجراءات التحكيم – لإيداع تلك الأتعاب لدى الهيئة خلال

المدة التي تحددها الهيئة، وفي جميع الأحوال تتولي الهيئة تعيين المحكم الثالث صاحب الدور أو غيره من الجدول بالتشاور مع محكمي الطرفين خلال ثلاثة أيام من المحكمين المسجلين لدى الإدارة، وتقدير أتعابه واستيفائها مناصفة بين طرفي التحكيم، وفي حال امتناع أحد الطرفين عن دفع نصيبه في تلك الأتعاب، يعرض الأمر على الطرف الآخر لدفعها في حال رغبته الاستمرار في الإجراءات وذلك خلال المدة التي تحددها الهيئة".

- كما أجاز النظام حق الاطراف علي الاتفاق علي المسائل المستعجلة حتي تكون من اختصاص هيئة التحكيم. حيث نص في المادة (٢٨) علي " يجوز لهيئة التحكيم – بناءً علي اتفاق طرفي التحكيم – نظر المسائل المستعجلة المتصلة بالنزاع المنظور أمام الهيئة، وإلا عرض الأمر علي القاضي المستعجل".

٢. مبدأ استقلال شرط التحكيم:

لقد كانت مسألة مدى ارتباط شرط التحكيم بالعقد الأصلي مثار جدل ، هل يعتبر شرط التحكيم جزء من العقد الأصلي أم هو اتفاق مستقل له ذاتية واستقلاله عن العقد الأصلي؟ وتبدوا أهمية هذه المسألة في حالة بطلان أحدهما هل يؤثر في الآخر؟ بمعنى أن إذا كان العقد الأصلي باطل فهل يؤدي ذلك إلي بطلان شرط التحكيم، و بالتالي يجب الذهاب إلي المحكمة لتسوية النزاعات ، أم أن ذلك لا يؤدي إلي بطلان شرط التحكيم وبالتالي يجب اللجوء إلي هيئة التحكيم لتسوية النزاعات ؟ ويمكن تلخيص المسألة بأن هل يرتبط شرط التحكيم بالعقد الأصلي بحيث يدور معه في نفس الفلك وجوداً وهدماً ؟

ولقد كان الرأي (القديم) قد اتجه إلي إنكار استقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي . والذي يدعوا الي تبعية شرط التحكيم العقد الأصلي، وبالتالي فإن شرط التحكيم يعد جزءاً من العقد الأصلي، فإذا ما أبطل العقد فإن شرط التحكيم يجب أن يلقي ذات المصير وهو البطلان.

إلا أنه نظراً للطبيعة القانونية لشرط التحكيم الذي يتمتع بقوة ذاتية ملزمة بالجوء إلي التحكيم لتسوية المنازعات ، وكذلك إلي كثرة إدراج شرط التحكيم في غالبية العقود التجارية ، فقد استطاع الرأي الحديث أن يتغلب على الاتجاه القديم ، وتكفل هذا النجاح بتبني معظم التشريعات المرتبطة بمجال التحكيم مبدأ استقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي (The Autonomous Nature Of the Arbitral Clause) .

وقد أسس هذا الرأي توجاً عالمياً يدعو إلى الاعتراف بمبدأ الفصل بين شرط التحكيم والعقد الأصلي

(The Principle of Seperability) حيث أن مجرد وجود شرط التحكيم في العقد الأصلي لا يدعو إلي التسليم بالقول بعدم استقلالية شرط التحكيم بل أنه يحتفظ بذاته واستقلاله وذلك للاعتبارات التالية:

أولاً : من الناحية المنطقية : أن الباعث والسبب في إبرام العقد الأصلي هو إتمام الصفقة وتنظيم الحقوق والواجبات المترتبة على هذا العقد ، في حين أن القصد من إدراج شرط التحكيم هو تحديد الجهة التي سوف تتولى الفصل في أي نزاع سوف ينشأ في المستقبل عند تنفيذ هذا العقد ، وهذه الجهة هي التحكيم وليس القضاء ، لذلك أن المنطق يستدعي التسليم بقبول فكرة استقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي ، حيث أن ما اتفق عليه الأطراف في شرط التحكيم يمثل الخطوة الأولى تجاه التحكيم ، وأن إرادتهم اتجهت إلي تسوية أي نزاع متعلق بهذا العقد الأصلي عبر التحكيم ، لذلك فإنه من الصعب قبول فكرة اندماج هذا الشرط في العقد الأصلي ، لا سيما وأن العقد يتطلب تنفيذ هذا الشرط و أحكامه ومتطلباته عند بدأ النزاع . فالحكمه من شرط التحكيم وموضوعه هو إلزام أطراف العقد الأصلي علي اللجوء إلي التحكيم ، فإذا ما حدث نزاع فإن مقتضى هذا الشرط هو اللجوء إلي التحكيم وليس قضاء الدولة . وبذلك نكون بصدد عقد داخل عقد. موضوع الأول هو تحديد الوسيلة الإجرائية لتسوية النزاعات التي سوف تنشأ في المستقبل، بينما موضوع الآخر هو تحديد الحقوق و الواجبات الموضوعية محل العقد. وبذلك يكون من المنطق قبول فكرة استقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي، وأن اتفاق التحكيم (شرط التحكيم) عبارة عن عقد آخر ذو طبيعة مختلفة عن العقد الأصلي وأن كان موجوداً من الناحية المادية فيه، فهذا لا يعني اندماجه في العقد الأصلي .

ثانياً : من الناحية العملية : أن هذا المبدأ من شأنه أن يساهم في منع الفرد الذي يرغب بتأخير العدالة وعرقلة سير إجراءات التحكيم ، وذلك بمجرد إثارة التساؤل حول مدى مشروعية وصحة شرط التحكيم عن طريق إثارة ذات التساؤل و الشبه إلى العقد الأصلي ، حيث أن فكرة استقلال شرط التحكيم تهدف إلى ترسيخ عدم تبعية شرط التحكيم للعقد الأصلي عدماً ووجوداً . فقد يكون العقد الأصلي باطلاً ولكن لا يعني ذلك بالضرورة بطلان شرط التحكيم ، والعكس صحيح فقد يبطل شرط التحكيم ولا يبطل العقد الأصلي ، ومثال ذلك أن يكون موضوع العقد غير صالح للتحكيم ، ففي مثل هذه الحالة يعتبر شرط التحكيم باطلاً ويلتزم الأطراف اللجوء إلى قضاء الدولة لتسوية نزاعاتهم في هذا الشأن.

أضف إلى ذلك ، أن فكرة استقلال شرط التحكيم يوفر الأساس لهيئة التحكيم بالنظر في النزاع والفصل في التساؤلات حول صحة العقد الأصلي ، حيث أنه وفقاً لمقتضيات شرط التحكيم يكون لهيئة التحكيم أن تفصل في النزاعات والادعاءات المتعلقة بمدى صحة ومشروعية العقد ، وبذلك لا يكون هناك مجال لتعطيل التحكيم لمجرد إثارة النزاع والتشكيك في صحة العقد . حيث أن هذه الأمور هي من صلاحيات واختصاصات هيئة التحكيم التي تتولى الفصل فيها كما اتجهت إرادة الأطراف في شرط التحكيم . فهو إذن يوفر أساساً مناسباً لمثل هذه السلطة وأن الحكم ببطلان العقد الأصلي لا يؤثر أبداً في مشروعية حكم التحكيم في هذا الشأن ، لأن هيئة التحكيم استمدت سلطاتها من شرط التحكيم وليس من العقد الأصلي . وبالمقابل فإذا انتهت هيئة التحكيم إلى أن شرط التحكيم باطل ، فإنه ينهي دورها ولا يؤثر هذا الحكم على العقد الأصلي ، وبالتالي يجب اللجوء إلى صاحب الاختصاص الأصلي وهو قضاء الدولة.

وبالتالي فإن الطبيعة الاستقلالية لشرط التحكيم تستجيب إلى مقاصد أطراف العقد ، وكذلك تلعب دوراً بارزاً في تفعيل نظام التحكيم ، حيث أنها تحد من أهمية الادعاءات ومشروعية وصحة العقد الأصلي و الذي لا يمنع هيئة التحكيم من مباشرة اختصاصاتها وسلطاتها ، وبذلك فإنه يجب – رغم هذه الادعاءات - اللجوء إلى التحكيم ، وكذلك يجب على المحكمة أن تحكم بعدم الاختصاص. وعلى هذه الاعتبارات ، أصبح هناك قبول شبه عالمي لمبدأ استقلال شرط التحكيم عند العقد الأصلي ، حيث تبنت المادة ١٦ من القانون النموذجي للأمم المتحدة هذا المبدأ ، حيث نصت على:

" ينظر إلى شرط التحكيم الذي يشكل جزءاً من عقد كما لو كان اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الأخرى . وأي قرار يصدر من هيئة التحكيم ببطلان العقد لا يترتب عليه بحكم القانون بطلان شرط التحكيم."

وكذلك فعل المشرع المصري في المادة ٢٣ من قانون التحكيم حيث أكد على أن شرط التحكيم يعد اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الأخرى ولا يترتب بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم الذي يشتمل عليه طالما كان هذا الشرط بذاته صحيحاً . فقد نصت المادة ٢٣ على أنه:

" يعتبر شرط التحكيم اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الأخرى ، ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه ، إذا كان هذا الشرط صحيحاً في ذاته."

وفي نفس الاتجاه ، قد سار المشرع الإنجليزي ، حيث قنن هذا المبدأ في المادة ٧ من قانون التحكيم لسنة ١٩٩٦ حيث قررت أن شرط التحكيم لن يعتبر باطلاً أو غير موجود أو عديم الأثر لمجرد أن العقد الأصلي باطل أو لم يوجد أو لم يكن له أثر ، من أجل ذلك فإن شرط التحكيم يعتبر اتفاقاً مستقلاً ومنفصلاً عند العقد الأصلي .

كما جاء نظام التحكيم الجديد في المملكة العربية السعودية في مادته (٢١) "يعد شرط التحكيم الوارد في أحد العقود اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الأخرى . ولا يترتب على بطلان العقد-الذي يتضمن شرط التحكيم-أو فسخه أو إنهائه بطلان شرط التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحاً في ذاته".

ولقد احسن نظام التحكيم الخاص بهيئة أسواق المال في دولة الكويت حينما تناول هذا المبدأ في مادته (٢)

"استقلالية شرط التحكيم:

يعتبر شرط التحكيم الذي يعد جزءاً من أي عقد كان مستقلاً عن شروط العقد الأخرى. ولا يترتب على الحكم بإبطال العقد الأصلي أو فسخه أو إنقضائه لأي سبب أي أثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه، إذا وقع هذا الشرط صحيحاً في ذاته".

٣. مبدأ سلطة الفصل في الصلاحية و الاختصاص:

مبدأ "صلاحية البت في الصلاحي Competence - Competence و الذي يكون بمقتضاه من صلاحية هيئة التحكيم البت في النزاعات المتعلقة في اختصاصها بما يشمل عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع . وفي غياب أي نص يحجب القضاء من النظر في مثل هذه الادعاءات فإنه لا مناص من التسليم بالقول بأن لها-أي القضاء- أن تتولى الفصل في هذه النزاعات، حيث يتعذر القول بعدم صلاحية المحكمة في النظر في صحة اتفاق التحكيم وتفسيره دون أن يكون هناك نص في هذا الشأن.

وجوهر المسألة أن المحكمة عند الدفع بالتحكيم يجب عليها – قبل أن تحكم بعدم الاختصاص – أن تتأكد من وجود اتفاق التحكيم الذي يسلب اختصاصها و أن هذا الاتفاق غير باطل أو لا يمكن تنفيذه ، فليس من المتصور أن تقوم المحكمة بتنفيذ عقد مخالف لنظام العام أو أنه لاغ أو لا يمكن تنفيذه. وهذا ما أكدته التشريعات الحديثة ، ومثال ذلك القانون النموذجي للأمم المتحدة حيث تنص المادة ٨ علي التالي:

"علي المحكمة التي ترفع أمامها دعوى في مسألة ابرم بشأنها اتفاق تحكيم أن تحيل الطرفين إلي التحكيم ، إذا ما طلب منها ذلك أحد الطرفين في موعد أقصاه تاريخ تقديم بيانه الأول في الموضوع النزاع ، ما لم يتضح لها أن الاتفاق باطل ولاغ أو عديم الأثر أو لا يمكن تنفيذه."

وهذا من شأنه أن يسمح للمحكمة أن تمارس سلطة المراقبة علي صحة اتفاق التحكيم و وجوده قبل أن تحكم بعدم الاختصاص. إلا أن هذه المسائل وفقاً للاتجاه الحديث هي من اختصاص هيئة التحكيم ، حيث أنه وفقاً لمبدأ "صلاحية البت في الصلاحية Competence - Competence يكون لها أن تفصل في المنازعات المتعلقة بأصل ونطاق سلطتها وبالتالي فإن هذا المبدأ يقضي بأن تترك المحكمة النظر في النزاعات المتعلقة باتفاق التحكيم لهيئة التحكيم ، حيث أن أطراف عقد التحكيم قد رضوا بأن يسلموا النزاع برمته لهيئة التحكيم لتفصل فيه ، وقد اتجهت إرادتهم إلي التحكيم ، فليس للقضاء أن يتدخل وينظر في اتفاق التحكيم . ورغم ذلك فإن هناك استثناء من هذا المبدأ وهو في حالة إذا كان بطلان اتفاق التحكيم ظاهراً ، ففي مثل هذه الحالة للقضاء أن يحكم في المنازعات المتعلقة بأصل ونطاق سلطة المحكم ، كأن يبدو لها أن موضوع العقد هو دين قمار أو أن يكون أحد أطراف اتفاق التحكيم عديم الأهلية . والغاية من إبقاء هذه السلطة للمحكمة هو تعزيز إجراءات العدالة ودعماً للتحكيم ، حتى لا يكون هناك فرصة لعرقلة العدالة وإضعاف فكرة قضاء التحكيم عبر الهروب من قضاء الدولة بمجرد وجود اتفاق تحكيم ، حيث قد يكون البطلان ظاهراً و واضحاً مما يجعل من الحكمة والعدالة ألا يجبر أحد الخصوم الخصم الآخر على الخوض في إجراءات التحكيم مصيرها في النهاية الفشل ، حيث أن حكم التحكيم عرضاً للبطلان لعيب في اتفاق التحكيم .

وقد نهج المشرع الفرنسي هذا النهج، حيث كان قد تبنى مبدأ اختصاص هيئة التحكيم بالنظر في المنازعات المتعلقة باختصاصها ونطاق سلطتها وذلك وفقاً لنص المادة ١٤٦٦ . إلا أن هذا النص لا يمنع المحكمة من الفصل في المنازعات المتعلقة بأصل سلطة المحكم ونطاقها إذا كان اتفاق التحكيم ظاهر البطلان ، حيث يفهم من نص المادة ٢/١٤٥٨ الذي ينص على عدم اختصاص قضاء الدولة بنظر المنازعات المتعلقة باختصاص المحكم إذا كان اتفاق التحكيم ليس ظاهر البطلان . ومن شأن هذا النص – بمفهوم المخالفة – إذا كان عقد التحكيم ظاهر البطلان فإن للمحكمة أن تنتظر في تلك النزاعات.

وكذلك الحال في القانون النموذجي الذي قنن "صلاحية البت في الصلاحية" في المادة ١٦ والتي تنص على "يجوز لهيئة التحكيم البت في اختصاصها، بما في ذلك البت في أي اعتراضات تتعلق بوجود اتفاق التحكيم أو بصحته". و نعتقد -وعلى ما قررته قضاء مجموعة من الدول التي أخذت بهذا النموذج في تشريعاتها - أن مبدأ "صلاحية البت في الصلاحية" لا يسلب سلطة المحكمة في النظر في اتفاق التحكيم و إنما يمنح فقط هيئة التحكيم السلطة بأن تفصل في المنازعات المتعلقة بأصل ونطاق سلطتها . ويدعم هذا الرأي نص المادة (٨) من النموذج والتي بينت إمكانية المحكمة التي ترفع أمامها دعوى في مسألة ابرم بشأنها اتفاق تحكيم عدم إحالة الطرفين إلي التحكيم ،إذا تبين لها أن الاتفاق باطل ولاغ أو عديم الأثر أو لا يمكن تنفيذه حيث تنص على الآتي:

" علي المحكمة التي ترفع أمامها دعوى في مسألة ابرم بشأنها اتفاق تحكيم أن تحيل الطرفين إلى التحكيم ، إذا ما طلب منها ذلك أحد الطرفين في موعد أقصاه تاريخ تقديم بيانه الأول في الموضوع النزاع ، ما لم يتضح لها أن الاتفاق باطل ولاغ أو عديم الأثر أو لا يمكن تنفيذه."

وقد سلك المشرع الإنجليزي ذات الاتجاه، فقد قررت المادة ٩ أن على المحكمة أن تنفذ اتفاق التحكيم ما لم يتبين لها بطلانه أو عدم إمكانية تنفيذه، وهذا الحكم جاء بهذا الوضوح رغم تقنينها مبدأ "صلاحية البت في الصلاحية" في المادة ٣٠ من قانون التحكيم لسنة ١٩٩٦ . وقد أكد القضاء الإنجليزي في أكثر من قضية على عدم التعارض بين المادتين سالفتي الذكر .

ومن ذلك يتضح لنا أنه إذا رفع نزاع إلى المحكمة في مسألة سبق الاتفاق على أن تكون محلاً لتحكيم ، وطلب المدعى عليه الحكم بعدم الاختصاص لوجود اتفاق التحكيم ، فإن الأصل أن تحكم المحكمة لصالح التحكيم ما لم يكن البطلان ظاهراً ، وهذا يعني أن هناك قيود على سلطة المحكمة في النظر في صحة اتفاق التحكيم وجوده ، فالمحكمة- كما نرى- ملزمة:

أولاً : أن تكون مؤيدة للاتجاه التحكيم ، وذلك استجابة لرغبة أطراف عقد التحكيم التي اتجهت إلى التنازل عن حقهم في التقاضي وتسوية منازعاتهم عبر التحكيم بذلك تكون المحكمة قد أيدت التحكيم واحترمت إرادة أطراف التحكيم. وهذا يوجب الأخذ في عين الاعتبار أن الأصل هو صحة اتفاق التحكيم ، ما لم يتبين لها العكس. بمعنى أن الفرضية الأولى هي صحة و مشروعية اتفاق التحكيم، إلا أن هذه الفرضية قابلة لإثبات عكسها . وهذا يدعوا المحكمة للفحص الظاهري وليس أن تبحث عن التفاصيل، كان تسأل من تلقاء نفسه عن تمتع الخصوم بأهلية إبرام اتفاق التحكيم.

ثانياً: أن تقدير القاضي لفكرة البطلان الظاهرة يجب أن يكون وفقاً للمعيار الضيق مما يعني أنه يجب أن يكون واضحاً لا نزاع فيه ، والذي لا توجد حجة جدية تثير الشك في وجوده ومثال ذلك أن يكون موضوع التحكيم غير قابل للتحكيم (مسألة جزائية أو متعلقة بالحالة الشخصية كالجنسية) . والهدف من ذلك هو الموازنة بين دعم التحكيم كقضاء خاص واحترام إرادة أطراف اتفاق التحكيم) أي احترام مبدأ سلطان الإرادة (The Principle of Party Autonomy ، و التأكيد على فاعلية التحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات وتوفير للجهد والوقت والمال . فليس للقضاء بعد أن تأكد من وجود ذلك البطلان الظاهري والواضح أن يسمح بالتحكيم الذي يصل حتماً إلى طريق مسدود نظراً للبطلان الذي يعيب ويعيق عملية التحكيم برمتها ويفسد ثمرتها.

ولقد أخذ نظام التحكيم الخاص بسوق المال في المادة (٢) " تختص هيئة التحكيم بسلطة الفصل في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفوع المتعلقة بوجود اتفاق التحكيم أو بصحته أو بعدم شموله لموضوع النزاع. ويجوز لهيئة التحكيم في - هذه الحالة - أن تفصل في أي من هذه الدفوع قبل الفصل في الموضوع كمسألة أولية أو أن تضمها إلى الموضوع لتفصل فيهما معاً".

٤. الشروط والصفات المشتركة بها المحكم

مما لا شك فيه ان التحكيم هو نوع من القضاء الخاص الذي يتميز بطبيعته الاتفاقية وظيفته القضائية . فإن كان مصدر التحكيم هو الذي يعكس المصدر الاتفاقي للتحكيم ، إلا أن هيئة التحكيم تعتبر المظهر القضائي في نظام التحكيم. حيث أنها تتولى مهمة الفصل في النزاع بحكم ملزم للخصوم . فالحكم يعد عنصراً جوهرياً في منظومة التحكيم ولا يتصور وجوده بدونه .ولذلك من المهم تسليط الضوء على الشروط والصفات المشتركة بها المحكم و هما الحياد والاستقلال.

نظراً لطبيعة القضائية لعمل المحكم فانه يشترط أن يكون مستقلاً ومحايداً ، على اعتبار أن هاتين الصفتين من الأمور الملزمة للوظيفة القضائية . بل أن من أهم الأسباب التي دفعت الخصوم إلى اللجوء إلى التحكيم هو حياد واستقلال هيئة التحكيم. وتجدر الإشارة إلى أنه ليس هناك تعريف عام لما هو مقصود من الحياد والاستقلال . إلا أنه يمكننا تقريب هذه المفاهيم بالقول بان جوهر فكرة اشتراط الحياد هو عدم وجود أي علاقة بين المحكم وموضوع النزاع بمعنى آخر هو ضرورة انتفاء المصلحة في النزاع . ويترتب على ذلك عدم جواز أن يكون للمحكم مصلحة من هذا النزاع حيث أنه مثل هذه العلاقة تثير الشك حول عدالة حكم المحكم فقد يتصور أن المحكم لم يحكم بهذا الحكم إلا لخدم مصلحة وهذا من شأنه أن يهدر عامل الثقة بين الأفراد

والتحكيم، ومن ثم فإنه من غير المقبول أن يكون المحكم مثلاً دائن أو كفيل أو ضامن للمدين وهو أحد أطراف النزاع أو أن يكون المحكم شريكاً في الشركة في نزاع بينه وبين الغير.

أما عن جوهر اشتراط فكرة الاستقلال هو عدم وجود علاقة بين أحد الخصوم والمحكم فوجود مثل هذه العلاقة من شأنها قد تؤثر في عدالة التحكيم . ويترتب على ذلك عدم جواز أن يكون المحكم قريباً أو صهرًا لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة أو غير ذلك من أسباب عدم الصلاحية والرد التي تم ذكرها في المادتين ١٠٢ و ١٠٤ من قانون المرافعات الكويتي . وهذه الأحكام وإن كانت تطبق أصلاً على القضاة فإنها كذلك يتم إعمالها في التحكيم حيث أن المحكم هو قاضي خاص يؤدي وظيفة قضائية.

ويتضح من ذلك أن الحياد والاستقلال من أهم معايير اختيار المحكم، إلا أن موقف التشريعات التحكيمية جاء مختلفاً تجاه هذه الشروط فمثلاً المشرع الإنجليزي تبنى فقط وجوب أن يكون المحكم محايداً دون الحاجة إلى التركيز على معيار الاستقلال حيث يذهب واضعوا التشريع الإنجليزي أنه ممكن أن يكون الشخص غير مستقل ولكنه محايداً فليس من الحكمة حرمان شخص لمجرد وجود علاقة بينه وبين أحد الخصوم رغم إمكانية أن يؤدي دوره على أكمل وجه وبشكل حيادي تام، أضف إلى ذلك أن وضع شرط الاستقلال في المحكم يتطلب وضع لائحة غير منتهية من الأسباب التي يكون من شأنها الطعن بالمحكم . وقد اعتبر المشرع الإنجليزي أن عدم الاستقلال لا يؤثر بحد ذاته على عدالة المحكم ، إلا إذا كان من شأن ذلك أن يؤثر الشك حول حياد المحكم .

وبالمقابل توجد بعض التشريعات التي استلزمت توفر هاتين الصفتين للمحكم، ومن ذلك القانون النموذجي للأمم المتحدة ، حيث قررت المادة ١٢ منه على ((لا يجوز رد المحكم إلا إذا وجدت ظروف تثير شكوكاً لها ما يبررها حول حيده أو استقلاله)) . وفي ذات الاتجاه قد سار المشرع المصري في المادة (١٨) التي تنص على ((لا يجوز رد المحكم إلا إذا قامت ظروف تثير شكوكاً حول حيده أو استقلاله)).

ونعتقد أنه من المهم توفر هذين الشرطين في المحكم ، حيث نعتبر هذين عاملين أساسيين لكسب ثقة الخصوم في هيئة التحكيم وعملية التحكيم وكذلك في حكم التحكيم، وهذا من شأنه أن يقلل من أسباب تأخير وتعطيل التحكيم أو التهرب من تنفيذه . أضف إلى ذلك أن كلا من الاستقلال والحياد تشكل جانباً أخلاقياً في العدالة التحكيمية وأن الإخلال بأحدهما يصلح سبباً في الطعن بالمحكم وحكم التحكيم، والطبيعة القضائية لدور المحكم تعزز هذا المذهب حيث أن المحكم يساهم في تطبيق العدالة مثل القاضي لذلك يجب توفر هذين الشرطين لتقديم عدالة للأفراد .

وقد اخذ نظام التحكيم الخاص بسوق المال بهذا النهج وجعل من أسباب رد المحكم خلال بقاعدة الحياد والاستقلال. حيث نص في المادة ١٠ على "لا يجوز رد المحكم إلا إذا قامت ظروف تثير شكوكاً جدية حول حياده أو استقلاله".

٥. واجبات المحكم:

من أهم هذه الالتزامات واجب لكشف عن أسباب الرد أو ما يطلق عنه بواجب الإفصاح (Duty of Disclosure) حيث تذهب بعض التشريعات إلى إلزام الشخص حين يعرض عليه مهمة التحكيم أن يصرح بكل الأسباب التي من شأنها أن تثير شكوكاً حول حياده واستقلاله. بمعنى أنه يجب على المحكم الإفصاح عند قبول المهمة عن أية ظروف من شأنها أن تبرر الشك في حياده أو استقلاله. ويبقى هذا التزام قائماً حتى بعد مباشرة المهمة إذا طرأ مثل هذا السبب بعد قبوله المهمة التحكيمية. وهذا ما جاءت به المادة (١٦) من قانون ١٩٩٤ المصري (يكون قبول المحكم القيام بمهمته كتابةً ويجب عليه أن يفصح عند قبوله عن أية ظروف من شأنها إثارة شكوك حول استقلاله أو حيده)، وكذلك القانون الأردني ٢٠٠١ (م١٦) والقانون التونسي ١٩٩٣ (م٥٧) والقانون العماني ١٩٩٧ (م١٦) وكلها كانت مستوحاة من نص المادة (١٢) من القانون النموذجي.

كما نهج نظام التحكيم السعودي الجديد في المادة (١٦) ذات النهج حيث نص على : " ١_ يجب ألا يكون للمحكم مصلحة في النزاع وعليه _ منذ تعيينه وطوال إجراءات التحكيم _ أن يصرح كتابةً لطرفي التحكيم بكل الظروف التي من شأنها أن تثير شكوكاً لها ما يسوغها حول حياده واستقلاله ، إلا أن سبق له أن أحاطها علماً بها "

ونعتقد بضرورة تقنين إلزام المحكم بالإفصاح عن كل الظروف والأسباب التي قد يكون من شأنها أن تثير شكوك حول حياده واستقلاله. إن هذا الواجب وإن كان مصدره أصلاً الواجب الأخلاقي للمحكم (Moral of Ethical Obligation) كما بينت أحكام جمعية التحكيم الأمريكية وجمعية المحامين الأمريكية وجمعية المحامين الدولية، إلا أن تقنين هذا الالتزام يجعله واجباً قانونياً على عاتقه في سرعة الإفصاح. حيث يتطلب قيام المحكم بدور إيجابي في مسألة عدم الصلاحية والرد ، ومؤكداً على ضرورة استمرار حياد واستقلال المحكم منذ قبوله إلى إنهاء إجراءات التحكيم ، وذلك على اعتبار أن الثقة في المحكم هي مبعث الاتفاق عليه، وأن هذا الإفصاح يهدف إلى إعلام الأطراف وتنبههم في مرحلة متقدمة عند اختيار المحكم بهذه الظروف والتي قد تمنع اختياره لمهمة التحكيم أو الاعتراض عليه. حيث أن الأصل هو عدم علم الشخص بسبب الرد أو عدم الصلاحية وعلى من يدعي خلاف ذلك أن يقيم الدليل على العلم بالسبب. كما أنه يوضح مدى شفافية المحكم وسعيه إلى القضاء بالعدل والإنصاف دون مبالاة لأحد، ويعبر عن حماية المحكم لسمعته، وحرصه وجهده في إنجاح التحكيم وأن لا يكون سبباً لتعطيل التحكيم مما يفقد نظام التحكيم من أهم سماته من سرعة وقلة التكاليف والسرية. كما يخفف من عبئ الخصوم بالبحث والتحري عن مثل تلك الظروف التي من المحتمل أن تقيم الشكوك حول حياده واستقلاله .

ولقد جاء نظام التحكيم الخاص بسوق المال متوافقاً مع هذا الاتجاه. حيث نص في المادة (٦) على واجب القبول والإفصاح.

" ١- يكون قبول المحكم القيام بمهمته كتابياً، ويجب عليه أن يفصح لدى الهيئة عند القبول عن أي ظروف أو أسباب من شأنها إثارة شكوك حول استقلاله أو حيديته، كما يجب على المحكم منذ تعيينه وطوال إجراءات التحكيم الإفصاح خلال خمسة أيام عند تحقق أي من هذه الظروف أو الأسباب.

وعلى الهيئة إخطار الخصوم بمضمون أفصاح المحكم لاتخاذ ما يرونه مناسباً خلال الخمسة أيام التالية على تمام الإخطار".

٦. الشمولية بالأحكام و البساطة باللغة:

نعم، يجب ان يمتاز اي نظام التحكيم بقدر الامكان علي كل الاحكام في نظام و تقنين واحد لرجوع اليه. كما انه يجب ان يخاطب الرجل العادي و ليس القانوني. فيجب استخدام العبارة السهلة الواضحة المباشرة بدون اية تعقيد.

وقد احسن نظام التحكيم الخاص بسوق المال الاخذ بهذي السياسة بشكل واضح و بطريقة مناسبة.

الحمد لله رب العالمين

الدكتور/ يوسف بن مبرك الصليبي العنزي

مدير الادارة القانونية – الادارة العليا- الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة